

刑法
No184

R1-3

(配点: 4)

月 日

月 日

承継的共犯に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】

- A. 共犯は、一個の犯罪を共同して行うものであり、後から犯罪に加担した者も、情を知って一罪の一部に加担した以上、犯罪全体について責任を負う。
- B. 共犯は、自己の行為と因果性がある範囲においてのみ責任を負うべきであって、自らが生じさせていない過去の事実について責任を負うべきではない。
- C. 先行者が生じさせた結果は承継しないが、先行者が生じさせた犯行を容易にする状態が存在する場合に、後行者がその状態を利用して犯罪を実現したときには、後行者も犯罪全体について責任を負う。

【記 述】

- ア. Aの見解に対しては、何を一罪として扱うかは、立法政策によって決まるため、一罪性に決定的な意味を認めるのは適切ではないとの批判が可能である。
- イ. Aの見解は、共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論に基づいて主張されるものである。
- ウ. Bの見解に対しては、複数の行為からなる犯罪で後行行為だけでは処罰されない場合に、処罰の空隙が生じるとの批判が可能である。
- エ. Cの見解に対しては、単なる憂さ晴らしにより他人に暴行を加えて抗拒不能状態にした後、財物奪取の意思が生じ、その状態を利用して同人から財物を奪取した場合、一般に強盗罪が成立しないとされていることとの比較から問題があるとの批判が可能である。
- オ. 甲がVに暴行を加えた後、なお強く抵抗するVに乙が甲と共謀の上で暴行を加え、Vが負傷したが、その傷害結果が共謀成立の前後いずれの暴行によって生じたかを特定できない場合、Cの見解からは、乙には傷害罪の承継的共犯は成立しないことになるのが自然であるが、この帰結は刑法第207条との関係で不均衡であるとの批判が可能である。

No184

R1-3

承継的共犯

正解

ア 1 イ 2 ウ 1 エ 1 オ 1

正答率

39%

ア 正しい

Aの見解に対しては、何を一罪として扱うかは、後行者の当罰性とは無関係な立法政策によって決まるものであり、一罪性に決定的な意味を認めるのは適切ではないことや、一罪という概念が多義的であり、それのみを理由とするのは実体を反映しない形式的な議論であるとの批判がなされている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

Aの見解の根拠は、一個の犯罪を二つに分解して論じることが許されず、また、共犯の罪名は正犯の罪名と同一であるべきという点にある。他方、因果的共犯論とは、共犯の処罰根拠を結果に対する因果性に求めるものであり、承継的共同正犯を限定的に肯定する見解又は否定する見解につながる。よって、Aの見解は、因果的共犯論から主張されるものではない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

Bの見解に対しては、詐欺罪や恐喝罪のように、複数の行為からなる犯罪で、後行行為だけでは処罰されない場合に、処罰の空隙が生じるという批判がなされている。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

本記述のように、いわゆる事後的奪取意思が生じ、財物を奪取した場合、強盗罪の成立が否定され、暴行罪と窃盗罪が成立すると解されている。他方、先行者が他人に暴行を加えて抗拒不能状態にした後、後行者がその状態を利用して犯罪を実現、すなわち財物を奪取した場合、Cの見解によると後行者には強盗罪が成立することになる。Cの見解に対しては、強盗罪において、暴行脅迫の効果が及んで強盗になるのは、最初から強盗行為の一部として盗取行為を行っている先行者のみであって、後行者は、それを共同にしたとしても、その行為の意味は、自分にとって窃盗行為にすぎないはずであるとの批判がなされている。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

本記述の事案の場合、Cの見解によると、Vはなお強く反抗しているから未だ乙の犯行を容易にする状態が存在するとはいえない。よって、傷害罪の承継的共犯は成立せず、暴行罪が成立するにとどまることになる。しかし、甲と乙の間に全く意思連絡がないのであれば、刑法207条が適用され、甲にも乙にも傷害罪の共同正犯が成立するはずである。それにもかかわらず、甲と乙との間に途中から共謀が存在した場合に、乙について傷害罪の共同正犯が成立しないとするのは、不均衡であるとの批判がなされている。したがって、本記述は正しい。